

1501722-97.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso (art.28, da Lei 11.343/06) ou, em caso de condenação, a aplicação do tráfico privilegiado.

É o breve relatório. Decido.

Não há preliminares ou prejudiciais ao mérito. Por outro lado, encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

3ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis-SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501722-97.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501722-97.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337212/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 21896471 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS,

1444/21/310 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 2337212 - 01º D.P. PENAPOLIS, 1444/21/310

- 01º D.P. PENAPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO DE OLIVEIRA FREITAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de SÉRGIO DE OLIVEIRA FREITAS, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, "caput", c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (fls. 94/97):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 09:45 horas, na Rodovia Assis Chateaubriand, km 294, nesta cidade e comarca de Penápolis/SP, SÉRGIO DE OLIVEIRA FREITAS, qualificado a fls. 08, transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, um tijolo de maconha, com peso líquido de 333,64 gramas do entorpecente, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e laudo de constatação provisória (fls. 30/33), caracterizando o tráfico entre Estados da Federação.

A denúncia foi recebida em 11 de abril de 2022 (fls. 165/166).

O réu foi citado (fl. 149) e apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (fls. 151/163).

Não tendo havido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 165/166).

Durante a instrução, colheu-se o depoimento de três testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão manifestada na denúncia, a fim de se condenar o denunciado como incurso nos tipos penais descritos na inicial acusatória.

A Defesa, por sua vez, apresentou as alegações finais por memoriais, nas quais postula a absolvição do réu por insuficiência probatória. Alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso (art.28, da Lei 11.343/06) ou, em caso de condenação, a aplicação do tráfico privilegiado.

É o breve relatório. Decido.

Não há preliminares ou prejudiciais ao mérito. Por outro lado, encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em virtude disso, avanço diretamente à análise do mérito.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (fl. 1); boletim de ocorrência policial (fls. 9/11); auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 30/33), laudo de exame definitivo químico-toxicológico, indicando que foi detectada a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC) nos materiais analisados (fls. 119/121); além dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial, quanto na instrução processual

A substância em questão, aliás, encontra-se presente na relação de substância de uso proscrito no Brasil, conforme o disposto na Portaria 344/98 do SVS/MS e suas atualizações.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha André Luiz Amancio da Silva,, declarou em juízo que, na qualidade de policial militar, atendeu à ocorrência policial. Afirmou que na data dos fatos estava realizando fiscalização na Rodovia Assis Chateaubriand; que deu sinal de parada para uma caminhonete; que, ao abordar o veículo, sentiu um forte cheiro de entorpecente; solicitou que os ocupantes do carro descessem; que perguntado se haviam feito uso de algum tipo de entorpecente, disseram que sim; que realizou revista no veículo e foi localizado, na parte dianteira, uma pequena quantidade de maconha; que ao questionar se havia mais droga no veículo, a esposa de Sérgio afirmou que sim; que ao revistar o local indicado, encontrou um tablete de maconha; que, ao indagar os ocupantes dos veículos, disseram que estavam realizando uma viagem a passeio, saindo de Cascavel com destino à Piauí; que Sérgio confirmou ter comprado o entorpecente na cidade de Cascavel/PR e que a droga se destinava para uso; que os ocupantes do veículo, Sérgio, sua esposa e Jefferson, afirmaram ser usuários de maconha; que com Sérgio foi encontrada a quantia de, aproximadamente, R\$3.000,00 e com Jefferson, a quantia de R\$6.000,00; que todos foram conduzidos ao plantão policial; que informaram que o dinheiro que possuíam era oriundo de venda de carros e seria usado durante a viagem; que a abordagem foi realizada na presença de todos os ocupantes; que não sabe informar se a pequena quantidade de droga encontrada na parte dianteira do veículo estava preparada para uso, mas que estava fracionada; que não se recorda se havia no veículo algum apetrecho que indicasse o uso; que foram apreendidos o dinheiro, o entorpecente e um aparelho celular; que na caminhonete havia diversas malas e pertences pessoais, caracterizando a viagem de longa distância; que havia algumas embalagens de presentes, sendo que os passageiros disseram que iriam ser entregues aos seus parentes em Piauí; que é policial militar há 20 anos.

A testemunha Isaque Borges dos Santos declarou em juízo que, na qualidade de policial militar, atendeu à ocorrência policial. Afirmou que estava realizando fiscalização no local dos fatos, quando foi abordada uma caminhonete com três ocupantes e uma criança; que, ao abordar o veículo, sentiu um forte cheiro de entorpecente; que em revista no veículo, foi localizada, na parte dianteira, uma pequena quantidade de droga; indagados aos condutores se havia mais droga, foi informado pela passageira que, no momento em que foi dada a ordem de parada pelos policiais, ela escondeu o restante da droga próximo a cadeirinha da bebê; que revistando o local indicado, foi encontrado o restante da droga; que Sérgio informou ter comprado a droga em Cascavel e que seguiria viagem para o estado do Piauí; que a droga seria para consumo; que foi apreendida quantia em dinheiro com Sérgio de, aproximadamente, R\$2.750,00 e, com Jefferson, a quantia de R\$6.000,00; que a abordagem foi realizada na presença de todos os ocupantes do veículo; que os passageiros relataram que iriam consumir a droga; que no momento da abordagem, o cheiro era típico da droga e que não havia fumaça; que foi fiscalizada a bagagem do veículo e não se recorda se havia embalagem de presentes.

Por sua vez, a testemunha Jefferson Calegari relatou, em juízo, que estava no veículo abordado; que os policiais sentiram o cheiro do entorpecente e realizaram busca no veículo; que foi encontrada a droga; que tinham saído de Cascavel/ PR com destino à Teresina/PI; que a viagem era a passeio, para visitar parentes e para trabalho; que a droga se destinava ao uso dos três ocupantes do veículo; que usaram a droga durante a viagem; que, no interior do veículo, havia papel de seda e uma faca e que tais itens não foram apresentados aos policiais; que foi apreendida a quantia em dinheiro de R\$2.750,00, pertencente à Sérgio, oriunda da compra e venda de veículos; que um dos motivos da viagem para Teresina era o comércio de carro ser mais barato por lá; que o dinheiro era para custear a viagem; que a quantidade e a forma de uso da droga varia conforme a situação; não sabe precisar quantos cigarros fuma por dia; que conhece Sérgio desde os 18 anos; que Sérgio é casado com sua irmã; que Sérgio sempre fez uso de entorpecente; que permaneceram em Teresina até 13 de janeiro; que visitaram outras cidades, como Porto Piauí, para Sérgio visitar seus parentes; que a mãe e a sogra de Sérgio também viajaram à Teresina; que um dos motivos da viagem foi para realizar a partilha dos bens; que Sérgio trabalhava como pizzaiolo em Cascavel/PR, e atualmente lida no comércio de veículos.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Sergio de Oliveira Freitas negou a prática delitativa. Disse que na data dos fatos foi abordado pelos policiais; que conduzia a caminhonete; que a droga foi encontrada próxima a cadeirinha de bebê; que além desta porção maior, foi encontrada uma pequena quantidade de droga; que a droga era pra uso; que levaram a droga para não ter que comprar no destino; que o motivo da viagem foi para visitar os familiares; que nasceu na cidade de Porto/PI; que um de seus familiares faleceu e foram até a cidade para regularizar o inventário; que foi apreendida quantia em dinheiro e seu celular; que o dinheiro era para o custeio da viagem; que sua mãe e sua sogra também viajaram até Teresina/PI; que passaram o natal e o ano novo juntos; que retornaram em meados de janeiro; que já tentou parar de usar drogas; que tem 37 anos, é amasiado há 10 anos e tem um filho de 02 anos; que estudou até a 8ª série, que trabalha com comércio de veículos; que sua renda mensal é de, aproximadamente, 6 mil reais; que já foi processado por receptação.

Conforme se verifica, os elementos probatórios colhidos na fase investigatória e, depois, em juízo formam um arcabouço firme e coeso, hígido o suficiente a demonstrar que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

A versão do acusado encontra-se isolada do conjunto probatório, indo de encontro às alegações dos policiais militares, os quais, em relato coeso e uníssono, detalharam, em juízo, as circunstâncias do flagrante de tráfico de drogas no qual prenderam o acusado.

Os depoimentos prestados pelos policiais foram coerentes e harmônicos com os demais subsídios de convicção existentes nos autos – especialmente com o laudo de constatação da substância entorpecente e principalmente o laudo toxicológico – e não há nenhum indicativo a colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas. Em verdade, o exercício da função de agente da lei não pode, por si só, tornar

suspeita a versão dos fatos apresentados, pois seria um contrassenso que o Estado incumbisse tais pessoas da função repressiva e lhes negasse crédito quando relatam suas diligências.

Com efeito, durante a abordagem policial, encontrou-se em poder do acusado, que conduzia veículo automotor de Cascavel/ PR com destino à Teresina/PI, a quantidade de 333,65 gramas de maconha.

O acusado não negou a propriedade da droga, mas alegou que seria para consumo dos ocupantes do veículo.

Diante desse cenário, sobretudo levando em consideração as palavras dos policiais, a autoria em relação ao denunciado resta, portanto, de todo comprovada nos autos, uma vez que droga foi efetivamente apreendida no veículo que era conduzido pelo réu, restando evidente a ciência e a conduta de transportar a droga.

No tocante à tipicidade do crime de tráfico de drogas em si, dentre outras modalidades descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, incrimina-se a conduta de transportar, bastando que a finalidade do agente não seja para consumo próprio.

E, no caso em apreço, em razão da quantidade de entorpecente (335,64 gramas de maconha – laudo de fls. 30/33), afastam-se as teses defensivas de absolvição por ausência de provas e de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo próprio.

Não se trata de quantidade desprezível de entorpecente e, aliada às demais circunstâncias em que ocorreu o flagrante e a apreensão conjunta da quantia de R\$ 2.750,00 em espécie, a quantidade não é ínfima o suficiente para tornar crível a versão de que o acusado é um mero usuário.

Apenas a título ilustrativo, levando-se em consideração os critérios objetivos adotados em Portugal (cf. Portaria nº 94/96), país que possui norma segundo a qual a quantidade de maconha compatível com o uso diário médio é de 2,5 gramas, verifica-se que a quantidade de droga que foi apreendida (335,64 gramas de maconha) é quase 135 vezes superior à quantidade de droga que o usuário médio, não dependente, faz uso por dia, avultando-se desarrazoado reconhecer a tese defensiva. Além disso, caso o entorpecente se destinasse ao uso próprio durante a viagem, teria havido apreensão de utensílios para o preparo e o consumo do tóxico, o que não ocorreu.

Por isso, não se mostra cabível acolher a alegação de que todo o entorpecente apreendido destinar-se-ia apenas ao consumo pessoal.

Dessa forma, devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, assim como a subsunção dos fatos à figura típica do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não há de se acolher as teses defensivas de absolvição, por insuficiência de provas, tampouco a de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, o conjunto probatório demonstra o transporte interestadual da droga, envolvendo dois Estados da Federação, com origem em Cascavel/PR e destino em Teresina/PI, a atrair a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, presente o elemento subjetivo do tipo, restando evidenciada a conduta dolosa do acusado, agindo com a vontade e consciência necessárias. A conduta típica é antijurídica, não havendo qualquer causa justificante para a realização dela. De acordo com a teoria da ratio cognoscendi, segundo a qual a tipicidade da conduta induz a antijuridicidade, a prova acerca da existência de uma justificativa fica a cargo da defesa, ônus do qual o réu não se desincumbiu. Em termos de culpabilidade, o acusado é imputável, já que maior de 18 anos de idade, além de não se enquadrar nas situações do artigo 26, caput e parágrafo, do Código Penal; tinha consciência da ilicitude de sua conduta; e lhe era exigível comportamento de acordo com o direito, não tendo sido suscitada hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Em observância ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, bem como ao artigo 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena segundo o método trifásico elaborado por Nélson Hungria.

Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, não extrapolou a normalidade do tipo.

Os antecedentes são desfavoráveis. Assim, utilizo-me da condenação definitiva no processo-crime nº 30179-71.2016.8.16.0021, com trânsito em julgado em 10/10/2016 (fls. 351 e 353), para negativa valoração nesta oportunidade. Não há elementos acostados aos autos para permitir a aferição da personalidade do réu e a sua conduta social. O motivo do crime não refoge à normalidade nesse tipo de ilícito. As circunstâncias e as consequências são normais ao tipo penal. Por fim, não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago, ou seja, não possui sujeito passivo determinado. Passando à análise específica das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que a natureza e a quantidade da droga já foram sopesadas para fins de subsunção dos fatos ao delito de tráfico, razão pela qual deixo de valorá-las novamente, evitando-se bis in idem. Logo, presente uma circunstância judicial negativa, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes de pena, devendo-se destacar que, nos termos do Enunciado nº 630 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". De outro lado, pesa em desfavor do acusado a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, decorrente da condenação definitiva no processo nº 0007465-83.2017.8.16.0021, com trânsito em julgado em 18/12/2017, conforme documentos juntados às fls. 420/439, razão pela qual agravo a pena intermediária em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, há que se considerar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, consoante exposto na fundamentação. Assim, majoro a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto), o que perfaz a reprimenda de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa. Destaque-se, no que tange ao reconhecimento de causa de diminuição de pena, que o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, prevê que "as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". No caso em exame, o réu não tem direito à causa especial de diminuição de pena, porque é reincidente, de modo que, objetivamente, denota-se a dedicação a atividades criminosas, impeditivo legal para a concessão da causa redutora.

À vista do quantum de pena aplicado e da reincidência, o regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade será o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Ressalte-se que, embora deva ser considerado para fins de detração, na forma do artigo 42 do Código Penal, o período de prisão preventiva não se mostra suficiente para influenciar na fixação do regime inicial.

Ante a ausência de dados concretos a respeito da situação econômica do réu, arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser devidamente atualizado no momento da execução, pelos índices de correção monetária adotados por este Tribunal (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal).

Conquanto o STF já tenha declarado inconstitucional a proibição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 (quatro) anos e o condenado é reincidente em crime doloso, o que impede a sua substituição por medidas restritivas de direitos (artigo 44, I e II, do Código Penal).

Igualmente incabível a suspensão da execução da pena, porquanto superados os dois anos previstos no artigo 77, caput, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), pois o crime é vago, não havendo vítima definida.

Por todas as razões expostas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu SÉRGIO DE OLIVEIRA FREITAS pela prática do crime

previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, do mesmo diploma legal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, estes fixados em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Tendo em vista o regime fixado para o início de cumprimento da pena, a reincidência e, ainda, a subsistência dos motivos que outrora fundamentaram o decreto preventivo, MANTENHO a prisão cautelar do réu, como forma de acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

Condene o(a)s sentenciado(a)s também ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de lhe conceder a gratuidade de justiça, pois não há elementos suficientes nos autos para, neste momento, reconhecer a hipossuficiência financeira alegada.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União (fls. 13/14), na forma do art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, os quais deverão ser revertidos diretamente ao Funad.

Por fim, deixo de conhecer do pedido de fls. 385/390, pois não cabe a este juízo de conhecimento estabelecer em qual estabelecimento prisional o acusado deverá ficar preso preventivamente e/ou cumprir pena.

Transitada em julgado da presente condenação:

- A) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006;
- B) coloquem-se os valores perdidos (fls. 13/14) à disposição da União (Funad);
- C) expeça-se guia definitiva de cumprimento da pena;
- D) intime-se o réu para pagar a pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 50 do Código Penal;
- E) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e
- F) lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Penápolis, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA